

1501390-91.2022.8.26.0540
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella
Comarca: Mauá
Foro: Foro de Mauá
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/08/2022
... de São Paulo:

Apelações criminais - Tráfico de substância entorpecente e associação para o tráfico - Sentença condenatória para o tráfico - Pretensão ministerial objetivando a condenação dos réus também pelo crime de associação, nos termos da denúncia - Defesa de Lucas voltada, em preliminar, à nulidade do processo por alegada ilegalidade na busca pessoal - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mauá
Foro de Mauá
2ª Vara Criminal
Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501390-91.2022.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501390-91.2022.8.26.0540
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JONATHAN HENRIQUE CORDEIRO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

JONATHAN HENRIQUE CORDEIRO foi denunciado por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 21 de julho de 2022, por volta das 22h20min, na Rua José Pedro de Assis, altura do número 20, nesta cidade e comarca de Mauá, o acusado guardava, trazia consigo, expunha à venda e vendia, para entrega a consumo de terceiros, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, descritas no auto de exibição e apreensão de fls. 22-3 e laudo de constatação de fls. 27-9.

Recebida a denúncia, o réu foi citado (fl. 83) e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução, as testemunhas arroladas pelas partes foram devidamente inquiridas. Por fim, interrogou-se o réu.

Em memoriais, pleiteia o Ministério Público a procedência da ação penal, enquanto a Defesa requer a nulidade da instrução por inobservância ao procedimento relativo ao acordo de não persecução penal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou, ao menos, a aplicação da pena nos patamares mínimos, com o reconhecimento do tráfico privilegiado e da causa de diminuição prevista no art.41 da Lei 11.343/06, a fixação de regime penitenciário inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Malgrado o esforço argumentativo do douto Defensor Público, a preliminar levantada não se sustenta. A questão atinente ao acordo de não persecução penal já foi devidamente afastada no momento oportuno (fls. 88-94).

No mérito, a acusação procede.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-2), boletim de ocorrência (fls. 03-5), auto de exibição e apreensão (fls. 22-3), laudo de constatação (fls. 27-9), laudos de exame químico-toxicológico (fls. 85-7), além da prova oral colhida.

Comprovou-se a autoria.

Interrogado, em solo policial (fl. 15), o réu permaneceu em silêncio. Em juízo, negou a acusação, alegando ser apenas usuário e dependente químico. Negou, ainda, estar na posse da pochete encontrada pelos policiais (mídia digital).

A negativa do réu está isolada do conjunto probatório.

Os policiais militares, na fase administrativa (fl.08-10), historiaram que: (sic) "em patrulhamento de rotina pela Rua Pedro de Assis, Jardim Elizabeth, nesta cidade, avistaram dois indivíduos em atitude de suspeição que estavam parados numa esquina e ao lado de um muro, os quais ao perceberem a franca aproximação da viatura policial passaram a empreender fuga em direção a uma viela, mas ao final foram alcançados e detidos. Que durante a busca pessoal foi encontrado sob as partes íntimas do implicado JONATHAS uma pochete que continha 44 pinos de cocaína, 85 invólucros de crack, 53 trouxinhas de maconha e R\$ 382,00 em dinheiro miúdo. Ao ser inquirido acerca da procedência das drogas, Jonathas admitiu que se dedica à mercancia ilícita e que recebe 10% de tudo o que era arrecadado com o trabalho proibido. Além disso, Jonathas indicou e levou a equipe policial até um muro onde ele estava antes da abordagem, onde de fato foram encontrados 412 pinos de cocaína, 535 trouxinhas de maconha, 736 de crack e, segundo o próprio investigado aquelas drogas haviam sido abastecidas por um indivíduo conhecido como Kilson."

Sob o contraditório, o policial militar José Carlos reiterou integralmente a dinâmica do ocorrido, confirmando que com o réu foi encontrada uma pochete com as drogas. Informalmente Jonathan admitiu a narcotraficância, explicando que vendia drogas há uma semana no local e recebia 10% das vendas. Questionado sobre a existência de mais entorpecentes, o réu conduziu-os até um muro, onde foi apreendido o restante das drogas (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de

menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

Observe-se que o depoimento prestado em juízo pelo policial militar além de plenamente coerente, está em perfeita harmonia àquele por ele prestado perante a autoridade policial. Ademais, não há qualquer motivo a que não possa ser atribuído total crédito a tal depoimento. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que tivesse motivo particular, injusto, para incriminar falsamente o réu.

Descabida a alegação da Defesa quanto à ilegalidade na busca pessoal, uma vez que os policiais responsáveis pela abordagem afirmaram que, durante patrulhamento de rotina, viram o réu na companhia de outro indivíduo, em atitude suspeita e empreendendo fuga assim que avistaram a viatura, de forma que as fundadas razões para a busca pessoal estão mais do que justificadas.

Neste sentido o e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Apelações criminais – Tráfico de substância entorpecente e associação para o tráfico – Sentença condenatória para o tráfico – Pretensão ministerial objetivando a condenação dos réus também pelo crime de associação, nos termos da denúncia – Defesa de Lucas voltada, em preliminar, à nulidade do processo por alegada ilegalidade na busca pessoal – Rejeição – Atitude suspeita dos acusados que justificaram a abordagem e a busca pessoal – Fundadas suspeitas da prática de crime evidenciada – [...] Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos. "[...] Segundo a prova dos autos, os policiais militares, no exercício de sua função, desconfiaram da atitude suspeita de agentes que, ao avistarem a viatura policial, demonstraram nervosismo, sem falar que já eram conhecidos nos meios policiais pela prática da narcotraficância. A atitude dos réus motivou a abordagem, ocasião em que foi localizado o entorpecente apreendido e razoável quantia. Vê-se, pois, que não houve qualquer violação aos dispositivos legais mencionados pela Defesa, sobretudo porque, repita-se, diante da atitude demonstrada pelos agentes, havia fundadas suspeitas para a realização da abordagem e busca pessoal." (TJSP; Apelação Criminal 1500126-68.2019.8.26.0047; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Assis - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/05/2022; Data de Registro: 04/05/2022). g.n.

Além disso, a quantidade de droga encontrada e as demais circunstâncias da apreensão, tais como a variedade e a forma em que era transportada, além do dinheiro localizado com o acusado, sem comprovação de origem lícita, trazem elementos suficientes de que ele tinha a droga para entrega a terceiros.

Dessa forma, entende-se que o delito de tráfico de drogas está fartamente comprovado.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base do réu em 1/6 acima do mínimo legal em razão da natureza das

drogas apreendidas - notadamente a cocaína e o crack, de alto poder vulnerante-, fator que justifica a majoração da reprimenda penal, na medida em que incrementa o potencial ofensivo à saúde pública (bem jurídico tutelado pela norma penal), revelando uma maior reprovabilidade da conduta do agente (STF, HC 73.097, rel. Min. Maurício Corrêa, HC nº 76.543-5, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC nº 35.539, rel. Min. Paulo Medina, HC nº 35.795, rel. Min. Nilson Naves, HC nº 35.159, rel. Min. Hamilton Carvalhido), perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Sobre o potencial lesivo da cocaína e do "crack" apreendidos:

"A cocaína pode produzir uma intoxicação grave e por vezes inesperadamente com pequenas doses. A dose letal pode estar entre 0,8 a 1,2 g para um homem de 70 kg. No entanto, fumadores de base livre reportam uso de quantidades que excedem a 1 g. Em contrapartida, há casos em que se pode ocorrer o óbito com uma dose extremamente baixa de 20 mg. Isto pode ser explicado pela ocorrência da tolerância reversa que se caracteriza ou pelo aumento da susceptibilidade ao aparecimento de convulsões em doses consideradas recreacionais ou por uma excitação aumentada obtida em doses menores em usuários crônicos, fato que pode ser explicado pela diminuição da biossíntese dos neurotransmissores, o que leva a uma potencialização dos efeitos excitatórios." (Passagli, Marcos; Toxicologia Forense - Teoria e Prática, 5ª ed., Millennium: Campinas, 2018 - pg. 180-1).

Quanto a possibilidade de aumento da pena-base em razão da natureza das drogas, destaca-se julgado do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"(...) Na primeira fase, a base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e em 500 dias multa, o que será mantida ante a inércia ministerial, posto que cabível aumento em face da natureza de parte dos entorpecentes apreendidos, que somente não será levado a efeito neste momento porque vedado a reformatio in pejus em recurso exclusivo da Defesa. Destaca-se inexistir bis in idem no uso da natureza em uma fase e a quantidade em outra. Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, a pena permaneceu inalterada. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento e diminuição, a pena definitiva resultou em 05 anos de reclusão e no pagamento de 500 dias-multa. O redutor não foi reconhecido em face da quantidade e diversidade de drogas, o que não merece reparos. Foi apreendida grande quantidade de drogas, suficiente para a confecção de cerca de 105 porções individuais de cocaína e 46 de maconha, além de 43 porções de crack. A grande quantidade de entorpecente apreendida denota que há profissionalização no tráfico de drogas, vez que a um iniciante e sem experiência na traficância não seria confiado montante substancial de entorpecentes. Portanto, a grande quantidade, indicativa de profissionalização, demonstra que a acusada se dedica a atividades criminosas e obsta a aplicação do redutor no presente caso." (TJSP; Apelação Criminal 1500309-78.2020.8.26.0540; Des. Rel. Mens de Mello; 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/07/2021) g.n.

No mesmo sentido o e. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E TERCEIRA FASES. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada. Na hipótese dos autos, não houve a incidência de bis in idem, pois, na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi elevada em razão da natureza do entorpecente e, na terceira fase, o redutor previsto na Lei de Drogas não foi aplicado devido à quantidade de droga apreendida. 2. Cabe às instâncias ordinárias, ao promover a dosimetria, considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las, na primeira fase, para exasperar a pena-base ou, na terceira fase, para graduar o redutor do tráfico privilegiado, mas nunca em ambas as fases, sob pena de bis in idem" (AgRg no HC n. 475.345/SP,

Ministro Félix Fisher, Quinta Turma, DJe 1º/3/2019). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 492.150/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 30/4/2019.) g.n.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DESCABIMENTO. REGIME FECHADO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE (ART. 44, I, CP). INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZ DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Como destacado na decisão agravada, cabe às instâncias ordinárias, ao promover a dosimetria, considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las, na primeira fase, para exasperar a pena-base ou, na terceira fase, para graduar o redutor do tráfico privilegiado, mas nunca em ambas as fases, sob pena de bis in idem. No ponto, importa destacar que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base no patamar mínimo previsto em lei. III - A quantidade, diversidade e nocividade das drogas apreendidas podem ser utilizada para fixação do regime mais gravoso do que o quantum de pena aplicada, por configurar maior gravidade na conduta, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06. Precedentes. IV - Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, não há que se falar em substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 475.345/SP, relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 1/3/2019.) g.n.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na última etapa, não deve incidir a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Diante das circunstâncias do delito, incompatíveis com traficantes "ocasionais" - o réu foi preso em flagrante com elevada quantidade de drogas, ou sejs, 588 porções de maconha (1.901g), 456 de cocaína (452g) e 821 de crack (355g), não comprovou de forma mínima o exercício de atividade lícita, além de ter dito ao milicianos que (sic) "se dedica à mercancia ilícita e que recebe 10% de tudo o que era arrecadado com o trabalho proibido" (fls. 08-10) - parece-me claro o acentuado envolvimento do acusado no comércio de drogas, ou seja, a não ocasionalidade da conduta.

Nessa linha, posiciona-se o e Superior Tribunal de Justiça:

"CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO "TRÁFICO PRIVILEGIADO (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, § 4º). IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 02. "A diversidade e a quantidade de droga justificam a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado" (HC 199.227/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/04/2015; HC 315.716/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 26/05/2015; HC 312.452/SP, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/04/2015). À luz desses precedentes e da premissa fática estabelecida no acórdão impugnado - o réu "trazia consigo e em momento anterior adquiriu droga, consistentes em 74,4 gramas de maconha, acondicionadas em 54 trouxinhas plásticas, e 36,07 gramas de cocaína, acondicionadas em 26 supositórios plásticos trouxinhas plásticas" -, não há como aplicar a causa de diminuição de pena do 'tráfico privilegiado' (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º). 03. Habeas corpus não conhecido"(STJ HC n. 317.721/SP Rel. Min. Newton Trisotto Quinta Turma DJe de 03/08/2015). g.N.

No mesmo sentido o e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"(...) Frise-se, por oportuno, a inaplicabilidade do redutor especial inserto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tal como decido monocraticamente. Como cediço, ao editar o mencionado dispositivo legal, o legislador objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, representado por aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual. Em outras palavras, para a situação do mercador novato de pequena expressão, o chamado "traficante de primeira viagem", como se pode qualificar aquele que possui "estoque" diminuto para negociar durante um curto período e, em regra, suprir o próprio vício é que a lei previu a benesse como forma de abrandar seu maior rigor punitivo. Nessa quadra, a par da primariedade, os elementos angariados aos autos demonstram, à saciedade, que as circunstâncias fáticas, concretamente recolhidas no curso das investigações e comprovadas em Juízo, são inconciliáveis com a traficância ocasional. Isso porque, o réu foi flagrado transportando e guardando exacerbada quantidade de entorpecentes (247 porções de maconha, 406 pinos de cocaína e 438 porções de crack), com naturezas extremamente destrutivas e nocivas, suficiente a atingir inúmeros usuários, de sorte a evidenciar a dedicação às atividades criminosas (narcotraficância). Nem se cogite a ocorrência do intolerável bis in idem, pois a quantidade dos entorpecentes, muito embora sopesada na primeira fase da dosimetria penal, não foi aqui considerada de forma isolada para o afastamento do benefício legal, ao contrário, as circunstâncias fáticas do flagrante policial (o que inclui natureza, quantidade e diversidade dos entorpecentes, situação de fuga à abordagem, em ponto com denúncias reiteradas da traficância), em conjunto, evidenciam dedicação habitual à atividade criminosa, sendo absolutamente implausível o reconhecimento do privilégio." (Apelação Criminal nº 1500603-96.2021.8.26.0540, Rel. Des. CLÁUDIA FONSECA FANUCCHI, j. 13 de dezembro de 2021).

Ainda sobre o redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06:

"(...) Cabe salientar que 'a conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade da droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas', para os fins a que alude o citado artigo de lei (STF, RHC nº 94.806, relatora Ministra Cármen Lúcia). Na realidade, a qualificação do agente como pessoa dedicada às atividades criminosas situação que afasta a incidência da causa de diminuição de pena estampada no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006 pode vir assentada na prova indiciária, tal como esta se acha definida no artigo 239, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado (artigo 155, do Código de Processo Penal), não se exigindo prova direta desta circunstância, sob pena de inviabilização da repressão penal a este tipo de delito, dada a dificuldade de se obter uma prova deste tipo (STF, HC nº 101.519, rel. Min. Luiz Fux). Consoante salientado pelo Ministro Luiz Fux, em passagem bastante elucidativa de seu voto, 'os criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada a atividades criminosas'. Deveras, na interpretação do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, há que se atentar para o elemento teleológico, na dicção do artigo 5º, da Lei de Introdução ao Código Civil (FRANCISCO AMARAL, Direito Civil, Introdução, Renovar, 12 edição, pp. 88/89; JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, Introdução e Teoria Geral, Renovar, 2ª edição, pp. 430/431), vale dizer, no sentido de que o escopo da lei foi de beneficiar com uma sensível redução da pena aquele agente que pela primeira vez se lança no mundo criminoso, cuja conduta não representa um maior perigo para a coletividade, de sorte que a pena reduzida, ainda que considerada a gravidade do tráfico de entorpecentes, afigura-se suficiente para a ressocialização e reprove

suficientemente o comportamento. Essa não é, decididamente, a situação dos réus." (TJSP, Ap nº 1501840-05.2020.8.26.0540, Des. Rel. LAERTE MARRONE, j. 28.04.21).

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. ANÁLISE DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA OU DE SER INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 1. A causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. [...] 3. A conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes: RHC 94.806/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/04/2010; HC 116.541/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2013; HC 98.366/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/2/2010. [...] (STF HC 121.057/SP Rel. Min. Luiz Fux j. 25.02.14 DJU 18.03.14).

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA, MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O §4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes dispõe a respeito da causa de diminuição da pena nas frações de 1/6 a 2/3 e arrola os requisitos necessários para tanto: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividades criminosas e não à organização criminosa. 2. Consectariamente, ainda que se tratasse de presunção de que o paciente é dedicado à atividade criminosa, esse elemento probatório seria passível de ser utilizado mercê de, como visto, haver elementos fáticos conducentes a conclusão de que o paciente era dado à atividade delituosa. 3. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções 'hominis' ou 'facti', pelo juiz, para decidir sobre a procedência do 'ius puniendi', máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como 'a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias'. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 4. Deveras, o julgador pode, mediante um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, utilizando raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 5. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. In casu, o

Juízo de origem ponderou a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (1,82g de cocaína pura, 8,35g de crack e 20,18g de maconha), destacando a forma como estavam acondicionadas, o local em que o paciente foi preso em flagrante (bar de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada." (STF HC 111.666/MG Rel. Min. Luiz Fux j. 08.05.12 DJU 23.05.12).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA: INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA: IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. [...] 6. Os fatos que deram ensejo à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Tóxicos são hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Paciente às atividades criminosas. 7. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. [...] (STF HC 109.236/SP Rel. Min. Cármen Lúcia j. 13.12.11 DJU 14.23.12).

Da mesma forma, incabível o pretendido reconhecimento do instituto da "delação premiada", prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/06.

Segundo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, para a incidência do referido instituto, os requisitos do mencionado artigo devem estar presentes cumulativamente. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. DELAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRETENSÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. REGIME FECHADO. QUANTUM DA PENA RECLUSIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a configuração da delação premiada (art. 41 da Lei de Drogas), é preciso o preenchimento cumulativo dos requisitos legais exigidos. Conforme consignaram as instâncias ordinárias, nenhuma colaboração foi prestada pelo Agravante no sentido de dados acerca do local e da pessoa que lhe forneceu os 21,70 kg de cocaína. 2. A elevação da pena-base foi adequadamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis que, de fato, emprestaram especial reprovabilidade à conduta do Acusado, mormente em se considerando a quantidade e qualidade do entorpecente apreendido. Por consequência, mantém-se o regime fechado (art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RESp 1301255/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 02/12/2013 - grifo nosso).

Na mesma linha, o e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06) - RECURSO DEFENSIVO [...] DELAÇÃO PREMIADA - Inviável a redução da reprimenda pela aplicação da delação premiada, quando não preenchidos os requisitos previstos no art. 41 da Lei n.º 11.343/06. [...] Anote-se que o art. 41 da nova lei de drogas menciona requisitos cumulativos para a aplicação da especial causa de diminuição e pela leitura do r. artigo, tem-se que é necessário que a colaboração possa ter efetividade para o desmantelamento de quadrilha ou bando criminoso, ou mesmo para a identificação de outro traficante, possibilitando que se possa oferecer denúncia e processamento do coautor. Desta feita, não há subsídios que apontem que a delação feita pelo apelante tenha se tornado objeto de investigação.

Destaco que, no momento da abordagem, seu comparsa conseguiu fugir e o apelante em nada colaborou para sua identificação ou captura. (TJSP; Apelação Criminal 1500713-03.2018.8.26.0540; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro: 18/11/2019).

Na hipótese, não houve qualquer colaboração por parte do réu para descoberta de eventual fornecedor ou outros colaboradores do narcotráfico. A mera indicação do local de armazenamento dos entorpecentes e do prenome de um suposto fornecedor, sem maiores esclarecimentos, não é suficiente para o reconhecimento da referida causa de diminuição de pena.

Registre-se, ainda, que sob o contraditório não houve qualquer cooperação, pelo contrário, o réu apresentou versão pífia de que era apenas usuário, com o fim de infirmar a prova já produzida.

Sobre o tema:

SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) [...] - DOSAGEM DAS PENAS EM CONSONÂNCIA COM O REGRAMENTO LEGAL, INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS E DO INSTITUTO DA DELAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 41 DO MESMO DIPLOMA LEGAL - REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO ADEQUADO À ESPÉCIE, MOSTRANDO-SE INADMISSÍVEL A CONCESSÃO DE QUAISQUER BENEFÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO. [...] Outrossim, no tocante ao pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 41 da Lei nº 11.343/06, anoto que a situação verificada nos autos não se amolda ao referido dispositivo. Não se perca de vista que a ré, em juízo, alterou sua versão dos fatos e alegou que atuava apenas como 'olheira' do tráfico, não contribuindo em momento algum com a identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, ausente, portanto, qualquer colaboração que permitisse desmantelar o grupo criminoso. Assim, nota-se que a ré apenas admitiu ao ser abordada o que foi constatado pela diligente ação policial e, pelo que se depreende dos relatos dos agentes públicos, indicou o barraco onde estava o restante das drogas e dinheiro pretendendo que com isso fosse 'liberada' pelos agentes públicos, não indicando sequer quem seria o proprietário do local (teria mencionado o nome de "Pamela" na fase de inquérito, porém não forneceu qualquer informação que permitisse a identificação de tal pessoa). [...] (TJSP; Apelação Criminal 1517865-93.2019.8.26.0228; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/06/2020; Data de Registro: 01/06/2020 - grifo nosso).

SENTENÇA CONDENATÓRIA DO APELANTE PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT), [...] - APELO DA DEFESA BUSCANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA REDUZIR AS PENAS, ACENANDO COM O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, APLICANDO-SE DO REDUTOR LEGALMENTE PREVISTO NA FRAÇÃO MÁXIMA E A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 41 DA LEI DE DROGAS, COM IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA DEVOLVIDA (CPP, ART. 599), [...] INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DELAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 41 DO MESMO DIPLOMA LEGAL PORQUE AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS [...] Outrossim, no tocante ao pedido de aplicação do instituto da delação, prevista no artigo 41 da Lei nº 11.343/06, anoto que a situação verificada nos autos não se amolda ao referido dispositivo, uma vez que o réu não colaborou com a identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime. Em verdade, CARLOS afirmou que RICARDO seria mero usuário de entorpecentes, a despeito de o corréu ter admitido em sede policial que era responsável por transportar os entorpecentes (fl. 6), não se insurgindo o Ministério Público a respeito. Tampouco indicou quem seria a terceira pessoa que fugiu por ocasião da abordagem policial, não havendo, portanto, nenhuma colaboração que contribuísse para desmantelar o grupo criminoso. Ressaltando-se, ainda, que as

drogas foram localizadas na residência após os policiais sentirem forte odor de maconha vindo do local. [...] (TJSP; Apelação Criminal 0061634-17.2018.8.26.0050; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020 - grifo nosso).

Estabiliza-se, assim, as sanções em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

O valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu.

Anote-se que o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 44 da Lei 11.343/06, nas partes em que se vedava a concessão de liberdade provisória (HC n. 104.339, rel. Min. Gilmar Mendes) e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (HC n. 97,256, rel. Min. Ayres Britto), bem como do parágrafo 1º do art. 2º da Lei n. 8072/90, que impunha o regime inicial fechado (HC n 111.849, rel. Min. Dias Toffoli).

Todavia, a gravidade in concreto do delito, considerando a quantidade e diversidade das drogas, assim como o alto potencial lesivo da cocaína e do crack para saúde pública, indica um grau acentuado de culpabilidade, de forma que o regime inicial fechado mostra-se necessário para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA. Possibilidade de fixar regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes.Ordem denegada.” (STF - HC 119.515/AC - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 03.12. - DJU 10.12.13)

Pelo mesmo motivo, não é hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, insuficiente para prevenção e reprovação da conduta.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR o réu JONATHAN HENRIQUE CORDEIRO, qualificado nos autos, a cumprir pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Denego ao réu o apelo em liberdade, mantidos os fundamentos da custódia cautelar.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, determino a destruição da contraprova das drogas, bem como o perdimento do valor apreendido, em favor do Funad, eis que comprovadamente obtidos com a narcotraficância, nos termos dos arts. 63 e 72 da Lei n.º 11.343/2006.

Defere-se os benefícios da justiça gratuita (fl. 133). Anote-se.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 19 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA